

1512565-48.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste prisma: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1512565-48.2022.8.26.0228 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 21 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de

Direito o(a) Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1512565-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

WENDER WALLACE CARRILHO RODRIGUES

Vistos.

WENDER WALLACE CARRILHO RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo de 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, porque, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 11h06, na Rua Cordão de São Francisco, altura do numeral 1125, Jardim Helena, nesta cidade e Comarca da Capital, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), trazia consigo e guardava, para fins de comercialização e consumo de terceiros, 07 porções de cannabis sativa L, com massa líquida de 10,0g, bem como 39 invólucros de cocaína, com massa líquida de 30,0g.

A denúncia foi recebida e a defesa preliminar foi apresentada.

Durante a instrução, foram juntados documentos, bem como foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (audiovisual).

Houve acordo de não persecução penal e descumprimento.

Memoriais (fls. 123/130 e 134/136).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de R\$79,00, 7 unidades de maconha e 39 eppendorfs de cocaína (fls. 12); pelo auto de constatação das substâncias cocaína e maconha (fls. 22/25); e pelo laudo de exame químico-toxicológico, em que se atestou tratar de substâncias psicotrópicas de uso

proscrito no país (fls. 79/80).

Quanto à autoria é inconteste, diante da prisão em flagrante do agente, na posse do entorpecente apreendido em circunstâncias de mercancia, conforme testemunhos policiais.

Vejamos a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Lindbergue de Lima Braga, policial militar, falou que estavam em patrulhamento e o réu estava em frente a uma mercearia, em pé, sozinho, com um volume embaixo da blusa em um comércio, o que ensejou a abordagem. Embaixo da blusa havia drogas maconha e cocaína e dinheiro. Ele admitiu o tráfico. Era porção pequena de drogas, que cabia em um estojo pequeno. Estavam de viatura com dois policiais. O comércio fica ao lado da praça, onde há passarela que atravessa a linha do trem. Geralmente ficam vendendo em cima da passarela. Havia a dona do comércio, clientes, além do réu. O réu não correu, mas demonstrou inquietação, ficou meio assustado. Seu parceiro fez a revista. O réu não disse ser usuário, mas que vendia drogas.

Leandro Ferreira de Souza, policial militar, disse que estavam em patrulhamento próximo de uma passarela, sendo que viram uma pessoa com volume na cintura. Em abordagem, com o réu havia um estojo com cocaína e maconha. Ele disse estar na venda e o conduziram. O réu estava andando quando o viram, ao lado de um comércio, vindo da passarela. Havia pessoas no comércio. Não se lembra da quantidade de drogas que foi encontrada. O réu tinha pequena quantia em dinheiro.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática dos fatos descritos na denúncia pelo réu.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, até mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste credibilidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF – HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94). O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF – HC 73.518- 5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96 – p. 39.846). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (STJ – HC 608.558 RJ 2020/0217527 – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 01.12.2020 – DJe 07.12.2020). Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

Ademais, o denunciado é confesso.

O réu WENDER WALLACE CARRILHO RODRIGUES afirmou ter 18 anos, morar com a mãe, avós, primo e irmão, trabalhar vendendo roupas de freelancer, mas estava sem dinheiro para mercadoria e por isso praticou a venda de drogas.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei de Drogas, fixa-se a pena base no mínimo legal para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em relação à atenuante da confissão e menoridade relativa, não se admite que a pena seja diminuída para aquém do mínimo. Nesse sentido, a Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Nesse mesmo sentido: Menoridade. Circunstância atenuante que, todavia, não pode implicar redução da pena fixada no mínimo legal (STF - HC - Rel. Sidney Sanches - RTJ 118/928). Ainda: (RT 737/551, 735/535, 735/568).

Consigne-se, quanto à agravante contida no artigo 61, II, j, do CP, que não há relação de causalidade entre o momento vivenciado no período de calamidade pública e a prática do tráfico de drogas.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de provas sobre a dedicação do réu a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo-se a pena em 2/3, totalizando-se 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do CP, fixa-se o regime aberto de cumprimento de pena. Não há que se olvidar que o tema 600 do Recurso Repetitivo do STJ dispõe: O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. E por ter respondido o processo solto, poderá apelar em liberdade.

Diante do exposto, CONDENO o réu WENDER WALLACE CARRILHO RODRIGUES às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os requisitos do artigo 44, caput, do CP e verificando-se que as medidas são socialmente recomendáveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, nos termos do artigo 46 do mesmo diploma, em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Criminais, descontado eventual período de custódia cautelar, e prestação pecuniária à entidade social no valor de um salário mínimo, que pode ser dividido. Nomeia-se a FUMCAD - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 8946-X.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste prisma: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. PENA. REGIME. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I - Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, o Plenário desta Corte, ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico, por ser incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. II - Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III - Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de piso que: i) superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para

a fixação do regime aberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada, e ii) afastado o óbice à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, analise se o paciente preenche os requisitos para a referida substituição. (HC 114029-SP - Rel. Ricardo Lewandowski - j. 18.02.2012 - DJe 22.02.2013). Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ - HC184497-SP - Rel. Jorge Mussi - j. 07.02.2013 - DJe 19.02.2013 e HC 216197-RS - Rel. Laurita Vaz - j. 07.02.2013 - DJe 18.02.2013. Também nesse sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva de habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quanto o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexistente a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do CP. 3. Quanto à possibilidade de substituição da pena, nos delitos de tráfico, o Supremo Tribunal Federal, em 1/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritiva de direitos. 4. No caso, tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, bem como considerada a quantidade não expressiva de droga apreendida, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 5. Habeas corpus não reconhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. (STJ - HC 463246 SP 2018/0200421-1 - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 18.10.2018 - DJe 26.10.2018).

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, expeça(m) ou adite(m)-se a(s) guia(s) de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; façam-se as comunicações; atualize-se o histórico de partes; archive-se; expeça(m)-se mandado(s) de prisão, se for o caso; uma vez cumprido(s), expeça(m)-se guia(s) de recolhimento, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), aguarde-se em escaninho próprio, cobrando-se a cada 120 dias; ou designe-se audiência para regime aberto; deverá(ão) o(s) réu(s) ser intimado(s) no último endereço onde foi(ram) encontrado(s); caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), expeça(m)-se mandado(s) de prisão, fazendo constar que o(s) réu(s) deverá(ão) ser imediatamente apresentado(s) a este Juízo para participar da audiência de regime aberto e, após, será(ão) posto(s) imediatamente em liberdade; o dinheiro deverá ser revertido em favor do FUNAD; se for o caso, requirite-se da autoridade policial a remessa da guia de depósito do valor apreendido, com prazo de 30 dias; findo, reitere-se, sob pena de crime de desobediência, oficiando-se à Corregedoria da Polícia Civil; fica(m) desde já o(s) réu(s) intimado(s) a pagar os dias-multa, em 10 dias a contar do trânsito em julgado, com consectários legais (Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta 139.521-1, Titular Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo); na hipótese de quitação, abra-se vista ao Ministério Público e, após, venham conclusos para declaração da extinção da punibilidade da pena de multa; caso não seja efetuado o pagamento da multa, encaminhe-se para cobrança.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
Juiz(a) de Direito